

1500278-20.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... em poder do réu seriam destinadas ao tráfico.

Ou seja, diante da prova produzida em juízo, não se pode afirmar, com a certeza que exige o decreto condenatório, que o acusado estivesse praticando o tráfico de drogas nas circunstâncias descritas na denúncia.

O acusado foi abordado ocasionalmente, sem qualquer investigação prévia ou campana e não foi visto pelos agentes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500278-20.2022.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500278-20.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026497/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 22713792 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2026497 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEBER MARTINS DOS SANTOS PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

CLEBER MARTINS DOS SANTOS PEREIRA está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, nas circunstâncias de tempo e espaço nela descritas, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 0,9g (nove miligramas) do entorpecente denominado "Metil Benzoil Ecgonina", vulgarmente conhecido como "cocaína", acondicionados em um 02 (dois) eppendorfs, além de 33g (trinta e três gramas) do entorpecente denominado "Cannabis Sativa L", vulgarmente conhecido como "maconha", acondicionados em 2 (duas) porções.

Notificado (fls. 100), o réu ofereceu defesa prévia (fls. 92/95) e a denúncia foi recebida (fls. 103/106).

Durante a instrução, inquiriu-se uma testemunha e interrogou-se o réu.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06 ou, em caso de condenação pelo crime de tráfico de drogas, a fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 e o direito de recorrer em liberdade. É o relatório.

Fundamento e decido.

Embora a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas em poder do réu esteja comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 71/73), o caso é de absolvição, pelos fundamentos a seguir expostos.

A posse do réu sobre os entorpecentes apreendidos é incontroversa.

Sua confissão, neste particular, está corroborada pela prova oral produzida em juízo.

O caso, entretanto, é de reconhecimento da ocorrência de porte de droga para uso próprio.

O policial militar Aldino relatou que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado em atitude suspeita e que ele tentou empreender fuga ao avistar a viatura. Disse que foi possível ver o acusado tentando descartar alguns objetos em uma residência e que, posteriormente, conseguiram abordá-lo e localizaram duas porções de cocaína, duas porções de maconha em seu bolso e uma quantia em dinheiro. Quando indagado, o acusado admitiu que estava comercializando os entorpecentes para sua subsistência. Salientou, por fim, que em outras oportunidades o réu já foi visto na mesma esquina em atitude suspeita.

Em seu interrogatório, o réu negou a prática do crime de tráfico de drogas e alegou que os entorpecentes eram para seu uso próprio. Disse que reside próximo ao local onde foi abordado e que costuma ficar na calçada conversando com alguns amigos.

Negou que tenha dito aos policiais militares que estava comercializando os entorpecentes e que tenha dito perante à autoridade policial que é traficante.

Pois bem.

A prova produzida sob o crivo do contraditório não demonstra, cabalmente, que as substâncias apreendidas em poder do réu seriam destinadas ao tráfico.

Ou seja, diante da prova produzida em juízo, não se pode afirmar, com a certeza que exige o decreto condenatório, que o acusado estivesse praticando o tráfico de drogas nas circunstâncias descritas na denúncia.

O acusado foi abordado ocasionalmente, sem qualquer investigação prévia ou campana e não foi visto pelos agentes policiais em contato suspeito com ninguém.

Nenhum outro objeto relacionado ao tráfico de drogas foi apreendido, como anotações, balança de precisão, faça, plástico filme etc.

A quantidade de drogas apreendidas (menos de 1g de cocaína e 24,390g de maconha) em sua posse, por si só, não denota a traficância, sendo perfeitamente possível que um usuário contumaz faça uso dela em poucos dias.

No que tange ao relato da testemunha de que o acusado costumava ser visto naquele local com frequência, cumpre salientar que o réu esclareceu que reside próximo de onde foi abordado e frequentemente permanece no local conversando com amigos, fato este incontroverso.

Portanto, o único elemento no sentido de que o acusado estivesse a praticar o tráfico seria a menção pela testemunha à suposta confissão informal do acusado quando abordado, o que obviamente não pode embasar o decreto condenatório.

Inexistente prova segura do tráfico, o caso seria de desclassificação da conduta do réu para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Ocorre que o reconhecimento da inconstitucionalidade material da norma penal incriminadora contida no art. 28 da Lei 11.343/06 é inarredável.

Inicialmente, deve-se ressaltar que não tem fundamento a falsa tese de que a lei teria descriminalizado o porte de droga para uso próprio, isto é, de que teria ocorrido a chamada abolitio criminis, ou mesmo de que a lei teria despenalizado tal conduta.

Ora, o art. 28 insere-se justamente no Capítulo III do Título III da lei 11.343/06, que trata precisamente "Dos Crimes e Das Penas", e dentre as sanções nele cominadas está a prestação de serviços à comunidade, que, por sua vez, é espécie de pena

prevista pela Constituição (art. 5º, inciso XLVI, d).

Portanto, não há a menor base jurídica para se afirmar que a lei teria deixado de considerar crime tal conduta, muito menos que a teria despenalizado, sendo absolutamente insustentáveis tais teses.

O problema, evidentemente, não está no âmbito da legalidade.

Ao contrário, o problema do mencionado art. 28 é que a lei não pode definir como crime qualquer conduta, indiscriminadamente, que não constitua lesão a direito de outra pessoa além do próprio autor da ação (princípio da alteridade), sob pena de violar o direito à liberdade, inerente a todo ser humano e assegurado pela Constituição em seu art. 5º.

Só existe crime, em sentido material, se a conduta constitui lesão efetiva ou, ao menos, coloca em perigo real o direito de outrem.

Numa linguagem mais informal, poderíamos dizer que a lei não tem “carta branca” para definir indiscriminadamente condutas criminosas.

Não pode a lei, por exemplo, dizer que é crime “usar peça de vestuário da cor amarela nas quartas-feiras”, porque isso simplesmente não lesa o direito de ninguém nem o coloca em perigo real.

Voltando ao caso do art. 28 em questão, não há como conceber que aquele que traz consigo pequena quantidade de droga para seu próprio consumo esteja lesando o direito de alguém. De que modo estaria a fazê-lo? A quem estaria lesando?

O sofisma de que tal conduta colocaria em risco a “saúde pública”, obviamente, não guarda nenhuma relação com a realidade.

De que maneira aquele que porta pequena quantidade de droga, para seu próprio consumo, infligiria algum perigo para a “saúde pública”? Ainda na remota hipótese de que a pequena porção de droga, por algum motivo fortuito (perda, por exemplo), viesse a sair de suas mãos, de que maneira ela representaria algum perigo à saúde de quem quer que seja, a não ser de alguém que se apropriasse dela e a utilizasse livremente (caso em que, obviamente, não haveria lesão nenhuma a seu direito).

Poder-se-ia argumentar, ainda, que o portador da droga, ao usá-la, poderia vir a cometer algum crime e, por isso, representaria um perigo à sociedade.

Este raciocínio é extremamente perigoso, porque a partir dele se deveria permitir, do mesmo modo, uma busca por infinitos outros fatores criminógenos e a consequente perseguição arbitrária, abusiva e tirânica de “potenciais criminosos” pelo estado. A este propósito, o filósofo, economista e historiador Murray Rothbard formula o seguinte princípio, que, sem dúvida alguma, deve balizar o âmbito de incidência do Direito Penal:

“(...) ninguém tem o direito de coagir qualquer pessoa que não esteja empenhada em um ato evidente de agressão contra direitos. Permitir um mínimo afrouxamento deste critério, para incluir coerção contra 'riscos' remotos, é sancionar agressões inadmissíveis contra os direitos dos outros. Além disso, qualquer afrouxamento deste critério é um passaporte para o despotismo ilimitado.” (in A Ética da Liberdade, Instituto Ludwig Von Mises Brasil, 2ª ed., p. 316)

O que se percebe é que, sendo impossível identificar-se na conduta de portar droga para uso próprio qualquer ofensa, ou mesmo perigo de lesão a direito alheio, gerado diretamente por tal conduta, a sua criminalização acaba por sustentar-se exclusivamente na reprovação moral do ato em si.

Ocorre que, obviamente, não cabe à lei criminalizar atos reputados “imorais”, desprovidos de qualquer potencial lesivo a direito de outrem (não existe o direito de exigir que outro indivíduo se comporte deste ou daquele modo), sob pena de se estabelecer inadmissível dirigismo autoritário de condutas individuais pelo estado. Portanto, é inevitável o reconhecimento da inconstitucionalidade material da norma penal incriminadora prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, por violar o direito fundamental à liberdade, sem que o justifique a defesa de nenhum outro direito que por tal conduta fosse violado.

Ante o exposto, desclassifico a conduta do réu CLEBER MARTINS DOS SANTOS PEREIRA para aquela descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06, e, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade material da referida norma penal incriminadora, pelas razões acima expostas, absolvo-o, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Uma vez que as partes manifestaram, em audiência, a renúncia ao direito de recorrer da presente sentença, certifique-se o trânsito em julgado.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

Fica autorizada a incineração das drogas apreendidas, na forma legal, oficiando-se à autoridade policial para tanto.

Determino, após o trânsito em julgado, a restituição em favor do réu da quantia apreendida em seu poder, uma vez que não ficou provada sua relação com o tráfico de drogas.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 28 de abril de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA